

1501101-17.2020.8.26.0157

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Rodrigo Pinati da Silva

Comarca: Cubatão

Foro: Foro de Cubatão

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... do art. 59 do Código Penal, o que também se aplica ao crime de tráfico [cf. STF - HC n. 111840, rel. Min. Dias Toffoli]. Segundo Leciona Cezar Roberto Bitencourt, "quando aqueles três fatores (art. 33, caput, combinado com o seu § 2º e alíneas) não determinarem a obrigatoriedade de certo regime, então os elementos do art. 59 é que orientarão qual o regime que deverá ser aplicado, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cubatão

Foro de Cubatão

2ª Vara

Av. Joaquim Miguel Couto, 320, Cubatão - SP - cep 11500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501101-17.2020.8.26.0157 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501101-17.2020.8.26.0157

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON APARECIDO DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pinati da Silva

Vistos,

I - RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio de seu representante legal, em exercício nesta Comarca, no uso de suas atribuições legais, com base em incluso auto de inquérito policial, ofereceu denúncia contra ANDERSON APARECIDO DA SILVA, tendo-o por incurso no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, imputando-lhe os seguintes fatos: no dia 27 de março de 2012, por volta das 18h20, na Avenida Nove de Abril, nº. 2068, Loja Still, Centro, nesta cidade e comarca de Cubatão, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 03 (três) mochilas da marca Sthill, 01 (uma) mochila da marca QuickSilver, a quantia de R\$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), em espécie, 10 (dez) bermudas das marcas Sthill e QuickSilver, bem como 40 (quarenta) bonés da marca Sthill, pertencentes à empresa vítima Sthill.

A denúncia foi recebida em 13 de agosto de 2021 [fls. 88/90].

O réu foi citado [fls. 107] e, por intermédio de defensor dativo, apresentou resposta à acusação [fls. 112].

Afastada a possibilidade de absolvição sumária [CPP, art. 397, fls. 114], foi designada audiência, na qual foram ouvidas as vítimas, bem como realizado o interrogatório do réu, com registro em mídia digital.

Em memoriais finais, o Ministério Público entendeu estar devidamente comprovada a materialidade e a autoria do delito, bem como a responsabilidade criminal do réu, pugnano pelo afastamento da causa de aumento referente ao concurso de agentes e sua condenação, discorrendo sobre a dosimetria.

Por sua vez, em seus memoriais, a Defesa do réu pleiteou sua absolvição, sustentando não existir prova suficiente para condenação [CPP, art. 386, V, VI e VII] e a desconsideração do reconhecimento do autor o fato pelas vítimas realizado anos após os fatos. Discorreu acerca da inexistência de boletim de ocorrência acerca dos roubos citados pelas vítimas e sobre o in dúbio pro reo e a presunção de inocência. Aduziu a inexistência de arma de fogo, bem como a comprovação do seu potencial lesivo através dos meios probatórios e, que diante a inexistência de provas juntadas aos autos, a mesma poderia estar na seara do armamento fantasia. Em caso de condenação, a desclassificação para o delito previsto no "caput" do art. 157 do CP e a aplicação da pena no mínimo legal, cumprido no regime semiaberto.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Processo em ordem, com a presença das condições da ação e observância das formalidades legais.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência [fls. 03/04 e 05/06], além da prova oral produzida em juízo.

A autoria é certa e deve ser imputada ao réu, porque comprovada pelas declarações dos ofendidos, auto de reconhecimento pessoal [fls.07/08 e 27/28] e prova oral. Wanderleia Alzira de Andrade, vítima, declarou que, no dia dos fatos, um indivíduo entrou na loja e logo "de cara" o reconheceu, pois já tinha acontecido algo semelhante em data anterior. O indivíduo levantou a camiseta, mostrou a arma e disse: "você já sabem o procedimento". Mandou pegar as mochilas dentro da loja e recolher bonés, óculos, relógios, camisetas e bermudas. Com as outras funcionárias encheu as mochilas e foi levada até o caixa para pegar o dinheiro. O roubador informou que tinha alguém o aguardando, mas não visualizou essa pessoa. A loja trabalha com multimarcas [volcom, vans entre outras]. Não se recorda da quantia que foi levada do caixa. Estava trabalhando junto com Alexandra e Renata. Assim que o indivíduo saiu da loja, gritou que havia ocorrido o roubo e acionou a polícia. Este ano, foi intimada para ir à delegacia e fez o reconhecimento pessoal do indivíduo sem dúvidas. Foi vítima em dois roubos diferentes. Os fatos narrados aconteceram em 2012 e o anterior no fim de 2011. Os bens não foram recuperados. O indivíduo estava com a "cara limpa", não usava boné. O indivíduo tem pele negra, altura mediana, tatuagem no braço e olhos escuros.

Em juízo a vítima reconheceu o réu sem dúvidas como sendo autor dos fatos. Destacou o rosto e a tatuagem do braço.

Alexandra Teixeira de Melo, vítima, declarou que o indivíduo sempre entra dizendo que é um assalto, mostra a arma na cintura e determina seja adotado o procedimento. A mesma pessoa já cometeu o delito em outras oportunidades e a forma de agir é sempre a mesma. Pede para encherem as bolsas com mercadorias e depois sai. O roubador levanta a camisa e mostra a arma. Não visualizou uma pessoa do lado de fora. O indivíduo não mencionou estar acompanhado de outra pessoa. Foram levadas roupas, bonés e óculos. Pode ter levado alguns "trocados", não sabe precisar valor. Não sabe como se deu a saída do indivíduo, pois ele pediu para ficarem trancadas no estoque até sua saída. Reconheceu a foto do indivíduo. A loja foi roubada cerca de nove vezes, nem todas as ocorrências foram registradas. A última vez em que a loja foi roubada foi entre os anos de 2019 e 2020.

Em juízo, a vítima reconheceu o réu sem dúvidas como sendo autor dos fatos. São características do roubador a sobrelanceira, o nariz e a boca.

Interrogado em juízo, o réu Anderson Aparecido da Silva negou os fatos. Disse não ter sido preso por este delito, foi preso em uma tentativa de assalto à loja "Poderoso Timão". Os policiais disse que iriam acabar com sua vida. Em 2013 foi preso em um assalto à joalheria na "09 de abril" e, no dia, os policiais disseram que iriam "empurrar esse b.o. da loja Sthill" para si. Foi levado para a delegacia para reconhecimento no primeiro DP de Cubatão e não foi reconhecido. No ano de 2017 foi autuado no porte de arma e associação e novamente foi levado para reconhecimento dos fatos ocorridos na nove de abril, também não sendo reconhecido. Disse ter sido reconhecido apenas após oito anos, já que nas datas anteriores, próximo ao fato narrado, não foi reconhecido pelas vítimas. Nega ter frequentado a loja Sthill. Em março de 2012, mês dos fatos, estava no Humaitá, na cidade de São

Vicente, local em que reside. Em 2011 portava uma arma e, ao tentar entrar em uma loja Sthill, em Santos, foi acusado de roubo mas conseguiu comprovar que só portava o objeto. Não conhece as vítimas do processo. Acredita a raiva dos policiais se dar pela ousadia dos fatos cometidos e por já ter sido preso anteriormente.

Essa é a prova oral constante dos autos.

Consigne-se que os inquiridos expuseram satisfatoriamente os fatos, sendo certo que os relatos são dignos de credibilidade, não se percebendo qualquer tentativa de falsear a verdade, porque convincentes e provenientes de pessoas cuja idoneidade não foi posta em dúvida, sem indícios de possuíam interesse em prejudicar o acusado, a quem não conheciam, ignorando-se nos autos notícia de desavença ou fato pretérito que indicasse falsa incriminação.

Interrogado em Juízo, o réu negou a veracidade da imputação.

A negativa inconsistente não infirma a versão das vítimas, tornando imperiosa a responsabilidade criminal do réu.

Tratando-se o roubo de crime clandestino tem especial relevância a palavra da vítima - que tem contato direto com o agente -, a qual, desde que coesa e harmônica, pode embasar o decreto condenatório, mormente considerando a presunção de que seu único interesse é o de apontar o verdadeiro culpado e não acusar inocentes injustificadamente [cf. STJ - AgRg no AREsp n. 297871, rel. Min. Campos Marques, j. 18.4.2013; TJSP Ap. n. 0017541-76.2012.8.26.0050, rel. Des. Lauro Mens de Mello, j. 25.9.2014].

E no caso as declarações da vítima revestem-se de coerência e segurança, não demonstrando qualquer tendência para o exagero ou falsidade, devendo ser aceitas como elementos hábeis à condenação, suportando o acusado, então, o ônus de contrastá-las, o que não fez a contento.

Oportuna a advertência constante de julgamento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pela relatoria do e. Des. Ricardo Dip: "É certo que, e isto o recruta de antecedentes de nossa Corte, vítimas podem errar no juízo da reconhecimento pessoal - e quanto ao reconhecimento de coisas -, por (a) sua sugestionabilidade, inclusa a atenção expectante, (b) deficiência perceptiva, (c) fragilidade na retenção das imagens, (d) complemento fabulativo da percepção fragmentária evocada, (e) vaidade, (f) orgulho obstativo da retificação de reconhecimento precipitado, (g) mentira inconsciente no histerismo, (h) propósito de falsear. Afirmar, todavia, essa mera possibilidade de erro das vítimas é, no fim e ao cabo, afirmar a defectividade comum do intelecto, da vontade e dos sentidos externos e internos de todos os homens, sem nada dizer, contudo, quanto à pertinência casual dessa crítica" [Ap. n. 0005342.08.2015.8.26.0635, rel. Des. Ricardo Dip, j. 20.06.2016].

Em juízo, as vítimas reconheceram o réu sem dúvidas.

Por si, o decurso do tempo, à vista da segurança das vítimas em juízo, imparciais, dada a ausência de interesse pessoal demonstrado, não afasta a legitimidade da prova.

Consigne-se que na fase policial as vítimas realizaram o reconhecimento fotográfico positivo. Acerca dele, confira-se: "O reconhecimento do acusado através de fotografias não encontra previsão legal. Porém, seja em virtude do princípio da busca da verdade, seja por força do princípio da liberdade na produção das provas, tem sido admitido pela doutrina e pela jurisprudência, sendo considerado espécie de prova inominada. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, é possível sua utilização, desde que corroborado por outros elementos de prova, sendo que o procedimento a ser observado é o mesmo do reconhecimento de pessoas (CPP, art. 226)" [LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. V. único. 2ª ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 675].

A grave ameaça que tipifica objetivamente o crime de roubo consiste na promessa da prática de um mal futuro, mas imediato e determinado, capaz de superar a capacidade de resistência da vítima, cujas condições pessoais, no contexto das circunstâncias fáticas, subsidiarão o livre convencimento do julgador acerca "[do] grau de temibilidade proporcionado pela conduta do agente" [STJ - REsp 951.841, rel. Min. Felix Fischer, j. 27.09.2007].

A propósito, Cezar Roberto Bitencourt ensina que "[o] mal ameaçado pode consistir em dano ou em simples perigo, desde que seja grave, impondo medo à vítima, que, em

razão disso, sinta-se inibida, tolhida em sua vontade, incapacitada de opor qualquer resistência ao sujeito ativo. No entanto, é desnecessário que o dano ou perigo ameaçado à vítima seja injusto, bastando que seja grave. Na verdade, a injustiça deve residir na ameaça em si e não no dano ameaçado” [Tratado de Direito Penal. Parte Especial, v. 3, 3ª ed., Saraiva, 2007, p. 85].

Na hipótese, como se viu pela prova produzida, sob o crivo do contraditório, estão presentes os requisitos fático-jurídicos configuradores da elementar do crime em exame, pois é certo que o crime foi cometido mediante grave ameaça, a causa de fato que levaram as vítimas permitirem que o réu subtraísse os bens. Obviamente, acreditaram que sofreriam mal grave e injusto.

A consumação do delito patrimonial, como o crime de roubo, segundo entendimento da doutrina majoritária e do E. Superior Tribunal de Justiça, ocorre com o apoderamento da coisa pelo agente, consoante a teoria da amotio ou apprehensio, após o emprego de violência ou grave ameaça, ainda que não seja retirada da esfera de vigilância da vítima e por curto espaço de tempo. Confira: STJ - AgRg no AREsp 433.206, rel. Min. Laurita Vaz, j. 26.8.2014. Assim, portanto, inarredável o reconhecimento da consumação do delito.

Assim sendo, a prova dos autos assegura que o réu subtraiu coisa alheia móvel, mediante grave ameaça, conduta que se adequa à figura típica prevista no art. 157, caput, do Código Penal.

A prova oral é firme quanto a circunstância relativa ao modo de execução do crime envolvendo o emprego de arma, prevista no art. 157, §2º, inciso I.

É desnecessária, para a configuração da causa de aumento de pena no roubo, a apreensão e perícia de arma quando a sua utilização puder ser demonstrada por outros meios de prova, como no caso [palavra da vítima], por se tratar de circunstância que não deixa vestígio. A propósito, confira-se: “Consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva” [EResp 961.863/RS]” (AgRg no Ag no RESp 1.561.836/SP, j. 19/04/2018).

Por seu turno, a prova dos autos não assegura concurso de agentes, sendo, nesse aspecto, contraditórias as declarações das vítimas. Uma das vítimas negou ter o réu referido a existência de pessoa fora do estabelecimento em comparsaria. De resto, o réu negou o delito e por extensão o concurso de agentes.

Assim sendo, o fato é típico e antijurídico, sendo certo que a significância da lesão ao bem jurídico tutelado impõe a incidência da norma penal, não estando o acusado amparado por qualquer causa de exclusão da ilicitude ou que afaste sua culpabilidade.

Passa-se à individualização da pena, nos termos do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, segundo o sistema trifásico, nos termos do art. 68 do Código Penal, atentando-se às circunstâncias legais, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

A culpabilidade, entendida como grau maior ou menor de reprovabilidade da conduta no caso concreto, é normal ao tipo. O acusado registra maus antecedentes, dada a condenação por fato anterior [22/12/2011, processo n. 937-30.2016, fls. 92], com trânsito em julgado posterior ao crime em análise [29/09/2015]. A conduta social, à míngua de elementos de provas objetivas desabonadores, é favorável ao réu. Sem desprezar o julgamento do RESp 1.794.854-DF, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 23/06/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 1077), no exame da personalidade, a partir do modo de agir e não de seu histórico delitivo, por si, “deve-se verificar a sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não de eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um episódio accidental na vida do réu” [Cezar Roberto Bitencourt, Tratado de Direito Penal, Parte Geral, v. 1, 12ª ed., Saraiva, 2008, p. 588]. Assim sendo, no caso, forçoso reconhecer personalidade desajustada, inclinada à prática criminosa com violência ou grave ameaça à pessoa, mormente considerando seu histórico infracional e especialmente o quanto retratado pelas vítimas acerca da habitualidade delitiva e

ousadia ao determinar adoção por elas do “procedimento criminoso” já conhecido. O motivo do crime integra sua definição típica, e, portanto, a necessária censura consta na pena mínima abstrata. As circunstâncias e consequências do crime são intrínsecas ao delito não exigindo maior reprimenda. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o impulso delitivo do agente, fato, todavia, que não agrava a pena por se tratar de circunstância neutra [cf. STJ - HC n. 217.819, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura].

Pena-base com acréscimo de um quinto.

Em segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a sopesar.

Pena intermediária sem alteração.

Na terceira fase, não há causa de diminuição de pena. Por outro lado, pela causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal, elevo a pena final em 1/3.

Na terceira fase, não há causa de aumento ou de diminuição de pena.

A pena definitiva é de 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, com 12 dias-multa.

Em vista da situação econômico-financeira do réu, fixo o valor do dia multa em 1/30 [um trinta avos] do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos [CP, art. 49], que será corrigido monetariamente na ocasião oportuna.

A fixação do regime inicial de pena deve observar os critérios da natureza, quantidade da pena aplicada, reincidência, além das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o que também se aplica ao crime de tráfico [cf. STF - HC n. 111840, rel. Min. Dias Toffoli]. Segundo Leciona Cezar Roberto Bitencourt, “quando aqueles três fatores (art. 33, caput, combinado com o seu § 2º e alíneas) não determinarem a obrigatoriedade de certo regime, então os elementos do art. 59 é que orientarão qual o regime que deverá ser aplicado, como o mais adequado (necessário e suficiente) para aquele caso concreto e para aquele apenado (art. 33, § 3º, do CP)” [Tratado de Direito Penal. Parte Geral.12 ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 450].

Pelas circunstâncias da execução do delito, o regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado.

Apesar da opinião diversa desse magistrado quanto à conveniência de se permitir que condenados por crimes praticados com violência ou grave ameaça cumpram pena em regime diverso do fechado, é inegável que a legislação penal vigente não faz distinção nesse particular, razão pela qual reiteradamente decide a Superior Instância consignando que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, fixada a pena-base no mínimo legal e sendo o acusado primário e sem antecedentes criminais, não se justifica a fixação do regime prisional mais gravoso (Súmula 440/STJ). 2. A Suprema Corte, nos verbetes 718 e 719, sumulou o entendimento de que a opinião do julgador acerca da gravidade abstrata do delito não constitui motivação idônea a embasar o encarceramento mais severo do sentenciado” [RHC n. 66895, rel. Min. Jorge Mussi, j. 15.3.2016]. Contudo, os dados fáticos da conduta delitiva, quando demonstrarem a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena. É o caso dos autos, pois foi empregada arma de fogo para subtração como meio de impor grave ameaça, circunstância objetiva que demonstra a intensidade do dolo, o vulto do risco a que se viu exposta a coletividade e as nefastas consequências sociais. Nesse contexto, é necessária resposta penal mais efetiva, como forma de retribuição proporcional à gravidade da conduta, de modo que o regime inicial mais brando não se revele suficiente para a reprovação e a prevenção do delito em comento, sob pena de indistigável impunidade, na contramão do anseio social voltado para a melhoria da segurança pública, mormente considerando a personalidade desajustada do réu, conforme fundamentação acima constatada a partir de seu histórico infracional. Descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos [CP, art. 44, III - antecedentes e personalidade] e a suspensão condicional da pena [CP, art. 77, II - idem].

A detração penal [desconto do tempo de prisão provisória] para fins de abrandamento do regime prisional inicial [CPP, art. 387, §2º] é descabida na hipótese por ausência do requisito objetivo.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e, em consequência, CONDENO ANDERSON APARECIDO DA SILVA, qualificado anteriormente, às penas de 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, com 12 dias-multa, no mínimo legal, por incurso no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal.

Atentando-se aos critérios de proporcionalidade previstos no art. 282 do Código de Processo Penal e dispensado o exame do fumus comissi delicti (existência do crime e indícios suficientes de autoria, na forma do art. 312, in fine, do CPP) pela fundamentação supra, afigura-se presente o periculum libertatis, uma vez que, diante da gravidade concreta do crime, praticado mediante grave ameaça à vítima com emprego de arma de fogo revelando a periculosidade do agente, imperiosa sua manutenção no cárcere para garantia da ordem pública, mormente considerando que a esse título permaneceu preso o réu durante o processo, medida provisória que se revela cabível e necessária (CPP, art. 313, I), por não se revelar suficiente sua substituição por medida cautelar diversa (CPP, art. 282, §6º), Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, também por outro delito [fls. 78]. Por fim, considerando inexistirem provas esquadrihadas e líquidas de eventuais danos materiais, deixo de fixar valor mínimo para reparação [CPP, art. 387, IV], o que não impede a busca dessa pretensão no juízo cível.

Nos termos do art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal, comunique-se ao ofendido.

Após o trânsito em julgado: (a) expeça-se guia de recolhimento para encaminhamento ao juízo das execuções criminais; (b) oficie-se ao TRE-SP, para os fins do art. 15, III, da CF e (c) oficie-se ao IIRGD para registro de antecedentes criminais.

Fixo os honorários advocatícios ao patrono do réu, nos termos do Convênio PGE/OAB, no máximo legal previsto na tabela, liberando-se 70% (setenta por cento) em caso de recurso.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas, nos termos do art. 804 do Código de Processo penal, ressaltando-se, como já se decidiu: "Ainda que os apelantes estejam assistidos pela Defensoria Pública, impõe-se a condenação ao pagamento das custas processuais, devendo a alegada miserabilidade jurídica ser examinada pelo Juízo da Execução, a fim de se conceder ou não a isenção reclamada (...)" [STJ, REsp 1416725/MG, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 29.06.2015].

P.I.C.

Cubatão, 24 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA